

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음3) 판사 C의 경우와 같이 제척사유가 있음에도 불구하고 법관이 스스로 직무집행을 피하는 제도인 회피의 절차와 효과에 대하여 기술하시오.》

<문제3.2의 물음3> 제척사유가 있는 법관이 스스로 직무집행을 피하는 회피의 절차와 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거 甲의 대리인으로 활동한 경력이 있어 제척사유의 존재를 전제로 스스로 직무집행을 피하는 회피가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <민사소송법상 법관의 회피가 인정되는 절차와 회피가 허가된 경우 발생하는 절차적 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 C의 회피 절차와 그에 따른 효과에 대하여 기술한다.

II. 회피의 의의 및 요건

1. 회피의 의의

- 회피는 법관이 자기에게 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하는 때에 스스로 당해 사건의 직무집행을 피하는 것을 말한다. 이는 법관의 양심과 명예를 존중하고, 불필요한 기피신청 절차를 생략하여 소송의 경제와 재판의 신뢰를 도모하는 데 목적이 있다.

2. 회피의 요건

- 법관은 자신에게 민사소송법 제41조(제척의 이유) 또는 제43조(당사자의 기피권)에 해당하는 사유가 있다고 판단될 때 회피할 수 있다. 사안의 판사 C와 같이 과거에 당사자의 대리인이었거나 사건에 실질적으로 관여한 바가 있다면, 이는 객관적으로 재판의 공정성을 의심받을 수 있는 상황이므로 회피의 요건을 충족한다.

III. 회피의 절차

1. 회피의 신청

- 법관은 회피하고자 하는 경우 소속 법원에 회피의 뜻을 표시하여야 한다. 이때 회피의 사유를 서면으로 소명하는 것이 원칙이다. 기피신청과 달리 당사자의 청구에 의하는 것이 아니라 법관의 자발적 의사에 의해 개시된다는 점에 특징이 있다.

2. 감독법원의 허가

- 회피는 법관이 임의로 결정하는 것이 아니라, 법원(감독법원)의 허가를 받아야 한다. 민사소송법 제49조는 감독권이 있는 법원의 허가를 받아 회피할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 법관이 자의적으로 재판을 기피하는 것을 방지하고 재판부 구성의 안정성을 유지하기 위함이다.

IV. 회피의 효과

1. 직무집행의 배제

- 회피 신청에 대하여 법원의 허가 결정이 내려지면, 해당 법관은 당해 사건에 관한 모든 직무집행에서 배제된다. 이후 해당 사건은 법원의 사무분담에 따라 다른 법관이나 재판부로 재배당된다.

2. 소송행위의 효력

(1) 허가 결정 전의 행위

- 회피 사유가 있음에도 허가 결정이 내려지기 전에 해당 법관이 행한 소송행위는 당연히 무효가 되는 것은 아니다. 다만, 제척사유가 있는 법관이 관여한 경우라면 이후 상소나 재심의 사유가 될 수 있다.

(2) 허가 결정 후의 행위

- 회피 허가 결정이 내려진 후에 해당 법관이 행한 소송행위는 직무권한 없는 자의 행위로서 무효가 된다.

3. 소송절차의 정지 여부

- 기피신청의 경우에는 법률상 절차 정지 규정이 명시되어 있으나, 회피는 법관의 자발적 신청과 법원의 내부적 허가 절차로 진행되므로 기피와 같은 엄격한 절차 정지 규정은 없다. 그러나 실무적으로는 회피 신청이 접수되면 허가 여부가 결정될 때까지 해당 사건의 심리를 중단하는 것이 통례다.

V. 결론

- 사안의 판사 C는 과거 甲의 대리인으로 활동한 경력이 있어 제척사유에 해당하므로, 스스로 회피 신청을 하는 것이 타당하다. 판사 C가 소속 법원에 회피 신청을 하여 허가 결정을 받으면 해당 사건의 재판부에서 적법하게 제외된다. 이러한 회피 제도는 당사자의 기피신청에 따른 불필요한 감정 대립이나 소송 지연을 막고, 법관 스스로 재판의 공정성을 확보하게 함으로써 사법 제도에 대한 국민의 신뢰를 높이는 중요한 기능을 수행한다.